



La Costituzione



Definizione



La Costituzione è il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma ad un ordinamento giuridico e ne definiscono i tratti essenziali.



Potere costituente e costituzione

Il potere costituente è quel complesso di forze politiche e vicende che dà origine ad una Costituzione.

L'esercizio del potere costituente attiene alla fase precedente la nascita della Costituzione.

Il potere costituente è difficilmente classificabile: può essere rappresentato da una rivoluzione, un colpo di Stato, o anche dall'elezione di un'assemblea costituente chiamata ad approvare una costituzione.

È un potere libero, non soggetto a regole. Il potere costituito (quello cioè creato dalla costituzione, è un potere sottoposto a limiti)

Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito.



Costituzione formale e materiale

- 
- **Costituzione formale:** è il documento solenne nel quale sono contenuti i principi e le norme supreme dell'ordinamento giuridico dello Stato (nei paesi di civil law è solitamente scritta)
 - **Costituzione materiale:** l'insieme dei valori e delle finalità attorno alle quali si è costituito l'ordinamento e di cui si fa portatrice la classe politica dominante in un determinato momento storico.



I caratteri della Costituzione: costituzioni scritte o non scritte

Scritta: le norme della Costituzione sono contenute in un documento scritto. La forma scritta serve a dare maggior solennità e certezza alle regole costituzionali

non scritta: le norme costituzionali non sono scritte ma sono prodotte da consuetudini formatesi nel tempo (es. Regno Unito)



costituzioni rigide e flessibili

Flessibile: sono flessibili le costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma questa può avvenire attraverso il normale procedimento legislativo;

Rigida: sono rigide le costituzioni che richiedono una procedura aggravata per la loro modifica (art. 138 Cost. italiana).

Per le costituzioni flessibili non è prevista una forma di controllo di costituzionalità delle leggi, poiché la legge che disponga diversamente dalla Costituzione prevale su quest'ultima. Le Costituzioni rigide invece prevalgono sulla legge e quindi la legge che disponga in contrasto con la Costituzione è invalida (è affetta da illegittimità per contrasto con una fonte superiore).



Segue:



Le **Costituzioni flessibili** sono tipiche del '800 (segnano il passaggio dalla titolarità assoluta del potere del Re ad un assetto in cui le decisioni sono adottate attraverso il procedimento legislativo dato dall'incontro della volontà del re e del Parlamento. La legge in quanto espressione di tale volontà, poteva modificare anche la Costituzione). Nelle costituzioni flessibili le enunciazioni sui diritti rappresentano un manifesto politico e lasciano al legislatore il compito di definirne il contenuto e le effettive garanzie.



Segue:

Le **Costituzioni rigide** si affermano nella seconda metà del 900, ma la prima costituzione che si impone come norma superiore e inderogabile dal legislatore è la Costituzione degli USA del 1787 (sentenza *Marbury v. Madison* del 1803).

La caratteristica della rigidità nasce per porre un limite al legislatore, al fine di impedire che le maggioranze che salgono al governo dello Stato abbiano la disponibilità delle garanzie poste dalla Costituzione a tutela delle minoranze. La legge quindi non può modificare le norme costituzionali sulla base di alcuni istituti che proteggono la Costituzione e le garanzie da essa previste (il procedimento di revisione costituzionale e il controllo di legittimità costituzionale delle leggi).

Sentenza *Marbury v. Madison* del 1803

La Corte Suprema Americana **dichiarò per la prima volta incostituzionale una legge del Congresso**, dando vita al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

La motivazione della decisione è ancora oggi considerata uno dei **fondamenti del diritto costituzionale statunitense**:

“O la Costituzione è una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha piacere di alterarle. Se la prima parte dell’alternativa è vera, allora una legge contraria alla Costituzione non è legge; se la seconda parte è vera, allora le Costituzioni scritte sono un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile”.

Tale pronuncia dà vita **al sindacato di costituzionalità diffuso** previsto negli USA



Costituzioni corte o lunghe

Corte: contengono poche regole e principi, essenzialmente sull'organizzazione dello Stato e su alcuni dei più significativi diritti dei cittadini (es: Costituzione USA)

Lunghe: non contengono solo principi, ma oltre all'organizzazione costituzionale dello Stato, disciplinano in modo dettagliato anche il rapporto fra i singoli e i pubblici poteri e i rapporti fra privati (la Costituzione italiana è una Costituzione lunga).



Costituzioni ottriate e votate

Ottriate (concessa): deriva da una concessione unilaterale del sovrano (es. lo Statuto Albertino)

Votata: approvata con la partecipazione del popolo (con l'elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione, oppure prevedendo il ricorso a referendum popolare per confermare il testo della Costituzione).



Costituzioni bilancio o programma

- **Costituzioni bilancio:** si limitano a fotografare la realtà esistente. Traducono in norme giuridiche gli assetti sociali e politici della comunità.
- **Costituzioni Programmatiche:** Le Costituzioni programmatiche individuano dei principi o obiettivi e attribuiscono al legislatore il compito di individuare gli strumenti, le politiche per raggiungere tali obiettivi (es.: la Costituzione italiana afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro (art. 1), che costituisce un diritto fondamentale (art. 4); enuncia l'impegno a perseguire l'eguaglianza sostanziale, ma tali enunciazioni necessitano di un intervento del legislatore al fine di trovare piena attuazione).

La Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica italiana del 1948 è stata approvata dall'assemblea costituente, eletta dal popolo contestualmente al referendum istituzionale del 2 giugno del 1946.

Costituisce la norma suprema dell'ordinamento, posta al vertice del sistema delle fonti
E' una Costituzione:

- **Rigida**
- **Votata**
- **scritta**
- **Lunga**
- **Programmatica**
- **Compromissoria**: è frutto di un compromesso raggiunto dalle diverse anime presenti in
Assemblea costituente rappresentanti culture diverse (quella liberal-democratica,
cattolica, marxista)



Le norme programmatiche della Costituzione italiana

- La Costituzione italiana, come tutte le Costituzioni della seconda metà del 900, contiene, accanto a **norme di natura precettiva** (dal contenuto dettagliato e di immediata applicazione) una serie di **disposizioni programmatiche** (da contenuto più ampio e generale) che necessitano di uno svolgimento legislativo al fine della loro attuazione.
- La distinzione fra norme precettive e programmatiche della Costituzione ha rappresentato l'«alibi» delle forze politiche che si sono succedute al governo dopo l'entrata in vigore della Costituzione e della stessa magistratura per lasciare inattuate intere parti della Costituzione (le norme sui diritti sociali (lavoro); il principio di eguaglianza sostanziale; norme organizzative: Corte costituzionale; Regioni....)
- L'orientamento diffuso fra la magistratura, infatti, fu quello di considerare norme giuridiche, e quindi cogenti, solo le norme precettive; **le norme programmatiche**, invece, furono considerate solo come **meri obiettivi politici indirizzati al legislatore** privi di carattere vincolante.

Segue: la sentenza della Corte costituzionale n. 1/1956

- Tutte le disposizioni costituzionali (siano esse programmatiche o precettive) operano come **norme giuridiche**, e hanno quindi **efficacia vincolante** nei confronti del legislatore e degli altri poteri dello Stato. Anche le norme programmatiche sono norme applicabili in giudizio
- Le norme programmatiche in quanto norme giuridiche implicano l'**OBBLIGO del legislatore** di dare ad esse **attuazione** ➡ Il carattere generale di tali norme lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta degli strumenti per attuare tali norme, ma si tratta di una **discrezionalità limitata dal principio della ragionevolezza** (dovendo il legislatore individuare scelte ragionevoli per il raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme programmatiche)
- Poiché le norme di carattere programmatico prescrivono **obblighi per il legislatore** e non meri obiettivi (le Costituzioni sono norme giuridiche, non manifesti politici), il giudice deve **sottoporre al controllo di costituzionalità** le leggi che contengono prescrizioni irragionevoli rispetto a tali norme (ad es. leggi che ostacolano, anziché favorire l'attuazione delle disposizioni programmatiche della Costituzione)

Il procedimento di revisione costituzionale

La Costituzione italiana prevede una procedura particolare, aggravata, per la modifica della Costituzione o per la formazione di leggi di rango costituzionale (art. 138).

Tale procedura prevede:

- **due deliberazioni successive** da parte di ciascuna Camera ad un intervallo non inferiore di 3 mesi l'una dall'altra (4 deliberazioni in tutto sul medesimo testo).
- **In seconda deliberazione** è richiesta la **maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea**
- Per la prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa. In questa fase le Camere possono approvare qualsiasi emendamento e il progetto è destinato a passare da una Camera all'altra fino a quando il medesimo testo non sarà approvato da entrambe.
- Nella **seconda votazione** **non** è possibile approvare **emendamenti** al testo votato in precedenza.



Segue:

Nella seconda approvazione si possono aprire due percorsi diversi:

1) se il progetto di modifica della Costituzione è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, la proposta di modifica della Costituzione revisione viene pubblicato in GU a scopo notiziale, ossia al fine di farla conoscere al popolo. Entro 3 mesi da questa pubblicazione, infatti, la proposta di modifica della Costituzione può essere sottoposta a **referendum confermativo**.

Il referendum può essere chiesto da **500.000 elettori** o da **1/5 dei membri di una Camera** o da **5 Consigli Regionali**.

Nel referendum costituzionale non è richiesto alcun quorum strutturale (il referendum è valido indipendente dal numero di partecipanti).



Segue: i possibili esiti dell'approvazione a maggioranza assoluta della modifica costituzionale

Nei 3 mesi che decorrono dalla pubblicazione del progetto di modifica costituzionale può accadere:

- a) Che non sia chiesto il referendum costituzionale: il progetto si ritiene tacitamente approvato dal popolo. Scaduti i 3 mesi, la legge costituzionale sarà promulgata e pubblicata in GU per la sua entrata in vigore
- b) Che sia chiesto il referendum:
 - se la proposta è approvata dagli elettori, la modifica costituzionale diviene legge perfetta e sarà promulgata e pubblicata in GU
 - se la proposta è rigettata dagli elettori, non vi sarà alcuna modifica della Costituzione



Segue: il ruolo del referendum costituzionale

Il ruolo del referendum confermativo è quello di consentire al popolo di **partecipare a formare la volontà espressa dal Parlamento**: la volontà espressa dal Parlamento **non è perfetta** se non è confermata dal popolo.

Solo a seguito dalla pronuncia popolare di approvazione del progetto di modifica della Costituzione, la legge di revisione costituzionale diviene una legge costituzionale perfetta e quindi sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in GU ai fini della sua entrata in vigore.

Se il popolo non approva la proposta di modifica, non avrà luogo alcuna modifica della Costituzione



Segue:

2) se il progetto di modifica della Costituzione è approvato dalla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei componenti dell'Assemblea, la legge costituzionale di revisione è approvata dalle Camere ed è promulgata dal PDR e poi pubblicata in GU ai fini della sua entrata in vigore.

La volontà espressa dalle Camere è una volontà perfetta che non ha bisogno dell'approvazione popolare in ragione dell'ampia maggioranza che ha approvato la modifica della Costituzione



I limiti alla revisione costituzionale: il limite esplicito della forma di Stato repubblicana



Non tutta la Costituzione può essere modificata. Un limite esplicito alla revisione della Costituzione è individuato **dall'art. 139 Cost.**, secondo cui “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. La forma repubblicana dello Stato, quindi, (il suo carattere democratico non può essere cancellata nemmeno con revisione costituzionale).



La teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale

La stessa Corte costituzionale, **nella sentenza n. 1146/1988**, ha affermato che esistono limiti impliciti, non esplicitati dalla Costituzione, alla revisione costituzionale, in quanto nella Costituzione sono contenuti alcuni **principi che rappresentano le basi valoriali su cui si fonda lo Stato** e che **non possono essere eliminati o compressi nemmeno con la procedura aggravata di riforma della Costituzione**.

La modifica nel loro nucleo essenziale o la soppressione di tali principi stravolgerebbe l'identità stessa della Costituzione.



Segue:

Non si tratterebbe più di una modifica della Costituzione, ma sarebbe come **dar vita ad una nuova Costituzione**, ad un nuovo assetto statale. Ma tale risultato non può avvenire con una procedura prevista dalla Costituzione, ma semmai con un **procedimento extragiuridico** (una rivoluzione, un colpo di Stato).

In sostanza, la Costituzione non può prevedere una procedura per negare se stessa.



Corte cost. n. 1146/1988

«La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

DI CONSEGUENZA.....



La competenza della Corte cost. a sindacare anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Corte cost. 1146/1988:

- «Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
- Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore».